Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Nova Alvorada do Sul
Vara Única

Autos: n. 0800972-90.2022.8.12.0054
Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Autor: Acácia Santos Martins
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Nova Alvorada do Sul - MS

SENTENÇA

I - Relatório

Acácia Santos Martins propôs a presente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face do Município de Nova Alvorada do Sul e Estado de Mato Grosso do Sul**,** visando compeli-los ao fornecimento dos fármacos Motilex (Colágeno não hidrolisado), Arpadol (Harpagophytum procumbens) e Flancox 600mg (Etodolaco). Alegou padecer de lombociatalgia crônica de forte intensidade (CID - M.51.1), razão pela qual necessita fazer uso continuo dos fármacos pleiteados. Sustentou que é obrigação dos requeridos o fornecimento do insumo que necessita, pois não tem condições financeiras para sua aquisição. Requereu, portanto, em tutela de urgência, a determinação para que os requeridos forneçam o medicamento necessário. Ao final, requereu a procedência do pedido e concessão do benefício da gratuidade da justiça. Juntou documentos (fls. 11-27).

De início, determinou-se a remessa dos autos ao NAT (fl. 31).

O NAT apresentou parecer favorável ao fornecimento de *Harpagophytum procumbens* (Arpadol) e, desfavorável ao pedido de Colágeno (Motilex) e Etodolaco (Flancox 600mg) (fls. 32-41).

A tutela de urgência foi parcialmente deferida apenas para a concessão do medicamento Harpagophytum procumbens (fls. 42-48).

O Estado de Mato Grosso do Sul juntou acordo celebrado com o Município de Nova Alvorada do Sul para o fornecimento do fármaco deferido liminarmente (fls. 67-71).

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação (fls. 72-83), alegando como preliminar, sua ilegitimidade passiva *ad causam*,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 18/09/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800972-90.2022.8.12.0054 e código ocSyjYx9.

ao argumento de que a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos do SUS é de competência da União. No mérito, suscitou que o pedido do requerente não preenche os requisitos cumulativos fixados no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, ante a ausência de provas da incapacidade financeira, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelos SUS.

Devidamente citado, o Município de Nova Alvorada do Sul/MS apresentou contestação (fls. 84-93), alegando como preliminar, ***(i)*** sua ilegitimidade passiva *ad causam*, ao argumento de que a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos do SUS é de competência da União e, ***(ii)*** o redicionamento da responsabilidade de fornecimento para o Estado de Mato Grosso do Sul, pelo fato do ente conseguir suportar o ônus financeiro. No mérito, suscitou que o pedido do requerente não preenche os requisitos cumulativos fixados no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, ante a ausência de provas da incapacidade financeira, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelos SUS.

A requerente apresentou impugnação a contestação (fls. 112-120).

A requerente e o Estado de Mato Grosso do Sul pleitearam o julgamento antecipado de mérito (fls. 126 e 128).

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. **Decido.**

II – Fundamentos

2.1. Do julgamento antecipado de mérito

O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que a matéria controvertida é exclusivamente de direito, prescindindo, portanto, de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2.2. Das Preliminares.

2.2.1. – Ilegitimidade passiva ad causam / Competência - inclusão da União

I - A preliminar apresentada pelo Município de Nova Alvorada do Sul/MS (***ilegitimidade passiva ad causam***), referente à ausência de responsabilidade pelo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 18/09/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800972-90.2022.8.12.0054 e código ocSyjYx9.

fornecimento do tratamento médico postulado, onde um atribui a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso do Sul, confunde-se com o mérito da causa, portanto, com ele será analisado. Ocorre que a discussão sobre a competência para a disponibilização do tratamento médico vindicado é questão de mérito, não guardando relação com os pressupostos processuais ou com as condições da ação.

Assim, a legitimidade passiva está presente, já que a parte autora apresenta em sua causa de pedir a alegação de que os requeridos possuem a incumbência legal de lhe disponibilizar tratamento médico necessário ao restabelecimento de sua saúde.

II - Em relação a preliminar alegada por ambos os réus sobre a incompetência do juízo em razão da necessidade de inclusão da União no polo da ação (Tema nº 793 de Repercussão Geral), destaco que a tese de repercussão geral fixada a respeito do tema 793, ficou redigida nos seguintes termos: ***Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,*** *e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.*

Em 25/05/2019, ela foi aprimorada no julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que o Min. Edson Fachin, que proferiu o voto condutor do acórdão, esclareceu o entendimento atual da Suprema Corte. Veja-se a ementa:

> *CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.* ***1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente*** *2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.* ***3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.*** *Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 18/09/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800972-90.2022.8.12.0054 e código ocSyjYx9.

> (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020).

Depreende-se, portanto, que a União somente deverá necessariamente integrar o polo passivo das ações que exijam o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, sendo que, nos demais casos, prevalece o posicionamento quanto à ausência de litisconsórcio passivo necessário, o que evidentemente não se aplica ao caso em tela.

Dito isso, rejeito tal preliminar.

2.3. Do mérito

No mérito, a pretensão da requerente é parcialmente procedente.

Toda pessoa tem direito ao adequado tratamento de saúde, decorrente do próprio princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, erigido à categoria de fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1.º, inc. III, da Constituição Federal.

Não bastasse isso, o art. 5.º, caput, da Constituição Federal discorre que: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

Sendo decorrência do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, pode-se dizer, sem qualquer dúvida, que a saúde é um direito fundamental do cidadão, e, como tal, tem a característica de vincular o Poder Público à sua estrita observância.

Além de configurar-se como direito fundamental e, portanto, de observância obrigatória pelo Estado, a própria Constituição Federal disciplina que a saúde é direito de todos e, conforme dito anteriormente, dever do Estado prestá-la, como se depreende do art. 196, a seguir transcrito: "*CF. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

A palavra "Estado" empregada no texto constitucional, a toda evidência (e até por questão de hermenêutica constitucional), deve ser interpretada em seu sentido *lato*, de modo a entender que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar assistência integral à saúde dos cidadãos (*trata-se de um direito*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 18/09/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800972-90.2022.8.12.0054 e código ocSyjYx9.

fundamental prestacional).

Em outras palavras, pela norma constitucional, há um dever solidário de assistência à saúde, o que significa dizer que **todos os entes políticos, seja qual for a esfera – Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, têm <u>responsabilidade solidária</u> no atendimento à saúde da população**.

A legislação infraconstitucional também impõe esse dever ao Estado (em sentido *lato*), ao dispor, no art. 2.º da Lei n. 8.080/90, posteriormente alterada pela Lei n. 12.401/2011, que regulamenta as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, que *"A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício".*

Por todos os ângulos que se observa a questão em análise, afigura-se visível que a pessoa que necessita ser submetida a cirurgia de elevado custo, e por não ter condição econômica para suportar as despesas dessa, tem o direito de receber do Estado – que por sua vez tem o dever de fornecer –, o meios necessários e imprescindíveis ao tratamento de sua doença.

É bem verdade que a Lei n. 8.080/90, em seu art. 7.º, IX, trouxe a descentralização do Sistema Único de Saúde, de maneira que cada esfera de governo ganhou autonomia e direção única para a gestão dos recursos destinados à saúde do cidadão. Também é certo que, em princípio, de acordo com a descentralização imposta pela Lei n.º 8.080/90, restou aos municípios, em caráter *preferencial* (art. 18, V, Lei 8.080/90), o dever de fornecer os medicamentos e tratamentos necessários à saúde do cidadão, já que recebe recursos do Sistema Único de Saúde para exercer o dever que lhe é imposto pela Constituição Federal.

Todavia, o fato de competir aos Municípios, em caráter principal, o dever desse fornecimento, não exclui o dever dos Estados e da União, de forma suplementar, assegurar a prestação desse serviço. Aliás, essa conclusão é facilmente alcançada pela leitura do art. 17, VIII, da Lei n. 8.080/90.

Nesse raciocínio, portanto, vê-se que **a responsabilidade não é subsidiária, mas principal**, o que significa que o Estado não está isento do dever de fornecer os medicamentos e os tratamentos não elencados como excepcionais, caso o Município, que tem o dever principal nesse fornecimento, não o fizer.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 18/09/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800972-90.2022.8.12.0054 e código ocSyjYx9.

A Lei 8.080/90 traduz uma divisão administrativa de atribuições, ***muito embora a responsabilidade perante o cidadão necessitado seja solidária***, quando descumprido o dever político-constitucional de fornecimento da assistência à saúde estampado na Constituição (art. 196).

Outra não poderia ser a conclusão, pois, como já dito, a Constituição Federal, em seu art. 196, ao fazer referência ao "Estado", alude a todos os entes políticos, independentemente de sua esfera de governo, de modo que eventual lei ou qualquer outro ato normativo que viesse contrariar essa regra estaria maculada pelo vício da inconstitucionalidade.

Portanto, à luz dos sistemas constitucional e legal, o cidadão pode pleitear a concessão de tratamento médico perante qualquer esfera governamental, pois o dever abarca todos os entes, que atuam na promoção da saúde num sistema de consórcio, mais precisamente, o Sistema Único de Saúde.

Nessa linha de entendimento colhe-se o seguinte julgado, proveniente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SERETIDE E BROMETO DE TIOTRÓPIO) - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DOCUMENTAÇÃO QUE ATESTA A INEFICÁCIA DE MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS - TUTELA ANTECIPADA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - FIXAÇÃO DE TETO LIMITE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO* ***1. A Constituição impõe a obrigação concorrente a todos os entes da Federação ao cumprimento do disposto em seu art. 196, independente de hierarquia, razão pela qual tanto o Município quanto o Estado pode ser compelido a fornecer o tratamento necessário à saúde do carente. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de conceder ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento, daí a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso do Sul.*** *[...].*
> (**TJMS** - AI: 40066486420138120000 MS 4006648-64.2013.8.12.0000, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 12/09/2013, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2014). (Grifei).

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

> *RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010)–* ***EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – PACIENTE PORTADOR DE ASTROCITOMA ANAPLÁSICA DO ENCÉFALO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 18/09/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800972-90.2022.8.12.0054 e código ocSyjYx9.

> ***IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.***
> (STF - EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: ARE 800051 RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/08/2014, Segunda Turma). (Grifei).

Com efeito, nada obstante a saúde seja reconhecida como direito de todos e dever do Estado, é certo que tal direito fundamental, consistente na assistência à saúde, individual ou coletiva, e em qualquer grau de complexidade, não é absoluto. Isso ocorre porque os recursos públicos são escassos e as demandas crescem em progressão geométrica, de modo que tal assistência pelo Estado deve ser propiciada nos limites das possibilidades do Poder Público, em razão da comprovada deficiência financeira que assola a maioria dos entes estatais.

Em complemento, destaco o entendimento exarado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, por ocasião do julgamento conjunto dos recursos n.º 566.471-RS e 657.718-MG, os quais tiveram repercussão geral reconhecida, cujo trecho na parte que interessa a seguir traslada-se:

> *Não há sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiros devam ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas. É preciso, tanto quanto possível, reduzir e racionalizar a judicialização da saúde, bem como prestigiar as decisões dos órgãos técnicos, conferindo caráter excepcional à dispensação de medicamento não incluído na política pública.*

Nesse passo, não se nega a possibilidade de se reivindicar do Estado o medicamento pretendido. Entretanto, não se pode desconsiderar que o oferecimento de tais fármacos, de modo irrestrito e desprovido de qualquer critério, sobrecarregaria em demasia o sistema de saúde brasileiro, o qual já se encontra em manifesto declínio.

Dessarte, deve o Poder Judiciário atuar com cautela e estabelecer parâmetros práticos para a sua concessão, cuja aferição deve se dar em cada caso concreto, com o propósito de enjeitar as hipóteses em que prescindível a atuação do Estado.

Através da análise de dos julgados proferidos pelos tribunais pátrios, que

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 18/09/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800972-90.2022.8.12.0054 e código ocSyjYx9.

envolvem a concessão de medicamentos, tratamentos e equipamentos àqueles que buscam tal prestação, é possível estabelecer certos critérios para um melhor exame do provimento jurisdicional pleiteado.

(i) Por primeiro, elenca-se que a destinação dos recursos públicos devem ser dirigidos àquelas pessoas que não dispõem de condições para a aquisição, por conta própria, de medicamento/tratamento, sob pena de subverter-se o propósito do direito pleiteado.

(ii) Já o segundo corresponde à essencialidade de laudo médico que corrobore a imprescindibilidade do medicamento ou tratamento prescrito ao paciente, de modo que a sua não utilização ou substituição por outro semelhante traduza em uma piora no quadro de saúde do enfermo.

(iii) Por último, mas não menos importante, necessário se mostra a efetiva comprovação do benefício à saúde do paciente, com a consequente melhora de seu estado clínico, com a finalidade de se afastar tratamentos experimentais, os quais se encontram em fase de teste, cuja eficácia e segurança não se encontram presentes.

Fixadas tais premissas, há que averiguar se elas se encontram presentes no quadro litigioso.

À vista do primeiro requisito, entende-se que ele se encontra preenchido, já que a assistida não dispõe de condições financeiras para arcar com o custo do medicamentoso, tanto que fazia seus atendimentos pela rede pública de saúde, além de estar assistida processualmente pela Defensoria Pública do Estado.

Mas, igual sorte não lhe assiste quanto aos demais critérios **em relação aos fármacos Colágeno (Motilex) e Etodolaco (Flancox 600mg).** Examinando os autos, verifica-se que os laudos acostados aos autos não atestam que os medicamentos seriam de urgência ou risco no caso da requerente.

Pois bem. O laudo médico de fls. 18-20 afirma genericamente que não há alternativa na rede pública para tratamento do problema de saúde da requerente, ao passo que o parecer do NAT indica tratamentos similares para a enfermidade, que são fornecidos pelo SUS (fls. 37 e 38, Item IX), vejamos:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 18/09/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800972-90.2022.8.12.0054 e código ocSyjYx9.

IX - Sugerir medicamentos ou tratamentos similares ao requerido, preferencialmente existentes no Sistema Único de Saúde (SUS) obrigatoriamente registrados na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de comprovada e equiparada eficiência ao requisitado judicialmente, com a mesma comodidade de uso e comparação de custo orçamentário;

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Dor Crônica, Portaria SAS/MS nº 1083 de 02/10/2012, oferece os medicamentos Ácido Acetilsalicílico, Dipirona, Paracetamol, Ibuprofeno, Amitriptilina, Nortriptilina, Clomipramina, Fenitoína, Carbamazepina, Gabapentina, Ácido Valproico, Codeína, Morfina, Metadona.

A RENAME 2022 tem padronizado no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) medicamentos analgésicos (Ácido Acetilsalicílico, Dipirona, Paracetamol), anti-inflamatório não esteroide (Ibuprofeno), corticoides sistêmicos (Dexametasona, Prednisona, Prednisolona, ésteres de Betametasona), antidepressivos (Amitriptilina, Nortriptilina, Clomipramina, Fluoxetina), antiepiléticos (Ácido Valproico, Fenitoína, Fenobarbital, Carbamazepina).

Veja-se que o único relatório médico acostado pela requerente sequer menciona quais os medicamentos já foram utilizados em seu tratamento, veja-se:

5. Existem tratamentos oferecidos pelo SUS para a doença citada com a mesma eficácia do tratamento indicado? Se afirmativa a resposta, qual(is)? Não

6. As alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS já foram utilizadas? ( ) Sim ( ) Não

Em caso afirmativo:
6.1 Especifique o período de tratamento e a resposta obtida: Ômegas

6.2 O(A) paciente faz uso de outro(s) tratamento(s) (farmacoterapêuticos ou não) para a doença? Qual(is)? FST / Aumentin

Ora, se o SUS disponibiliza outros meios para o tratamento do mesmo diagnóstico e inexiste nos autos prova de que aqueles substitutivos não seriam eficazes ao tratamento da moléstia suportada pela autora, não parece legítimo obrigar o Poder Público

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 18/09/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800972-90.2022.8.12.0054 e código ocSyjYx9.

a ofertar outros medicamentos se não aqueles disponibilizados na rede municipal de saúde.

Nesse sentido, correlaciono os seguintes julgados do TJMS:

> *APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REFORMADA.* ***FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E DA INEFICÁCIA DAQUELES REGULARMENTE DISPONIBILIZADOS PELO SUS.*** *TESE DO STJ – TEMA 106. RECURSO PROVIDO.* ***Não é razoável exigir do Poder Público medicamento específico, diverso daquele regularmente disponibilizado pelo SUS, especialmente não havendo comprovação da ineficácia deste último ou mesmo da imprescindibilidade da prescrição médica.***
> (**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 2000756-96.2022.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile, j: 17/01/2023, p: 18/01/2023) (grifei)
>
> *REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO - INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) -* ***EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO DISPONIBILIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS GRATUITAMENTE FORNECIDOS PELO PODER PÚBLICO NO CASO CONCRETO - PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE*** *– REQUERENTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONFUSÃO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO ESTADO PROVIDOS - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO. [...] 3 - Em que pese a saúde ser direito de todos, consoante respaldo constitucional (arts. 23, II, e 196), a procedência de toda e qualquer ação fundada no tema, conforme vinha ocorrendo sob esse fundamento constitucional genérico e abstrato, terminava por produzir um verdadeiro caos no orçamento público, pois exigia a adoção de providências sem qualquer lastro de previsão financeira, impactando demasiadamente nos cofres públicos e na própria condução das demais políticas públicas, ante a manifesta escassez de recursos. 4 - Ademais, sendo a saúde espécie do gênero seguridade social, e o fornecimento de remédios uma das várias prestações deste, devem ser observados os princípios básicos que subsidiam o sistema da Seguridade, in casu, a seletividade (art. 194, par. ún., inc. III da Constituição Federal), princípio voltado ao legislador e ao administrador público, que devem eleger quais contingências estão aptas ao resguardo pelo Poder Público, pautado no ideal de prestações que comportem a mais ampla proteção social possível, tendo sempre por norte a solidariedade como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º da Carta Magna). Nesta toada, interessante pontuar que quando conveniente, tanto legislador quanto o gestor público (claro que a este dentro da discricionariedade administrativa proporcionada pela norma), selecionam as prestações (medicamentos e procedimentos) devidos à população, como por exemplo, a distribuição de medicamentos para o combate do vírus HIV, direito subjetivo amparado pela Lei nº 9.313/96, ou os medicamentos distribuídos pelo SUS na rede pública de saúde. 5 -* ***Se há tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não há razão para o Judiciário interferir nas decisões legislativas e administrativas sobre a pretensa justificativa da existência do direito fundamental à vida e à saúde, afinal, as leis devem ser compreendidas dentro de um sistema interpretativo que promova a harmonia entre as normas que o compõem, sem interpretações isoladas e, no mais das vezes, desastrosas à implementação de políticas públicas. 6 - A flexibilização desse raciocínio pelo Judiciário só seria possível ante as peculiaridades do caso concreto, anotadas à situação urgente em que há o risco iminente à vida do paciente e a utilização anterior dos medicamentos ou demais***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 18/09/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800972-90.2022.8.12.0054 e código ocSyjYx9.

> ***procedimentos prestados pelo SUS, além de não tratar-se de tratamento experimental – pelo qual as incertezas de seus efeitos subsidiam a obstaculização de seu fornecimento pelo juiz, com amparo no princípio da precaução. 7 – Não tratando-se, in casu, de situação que excepciona a orientação firmada, a revogação da liminar concedida é medida que se impõe.*** *[...] 9 - Reexame necessário e recurso de apelação dos Estado de Mato Grosso do Sul providos. Recurso da Defensoria Pública Estadual prejudicado.*
> (**TJMS**. Apelação / Remessa Necessária n. 0801303-16.2019.8.12.0042, Rio Verde de Mato Grosso, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 20/09/2021, p: 21/09/2021)

Ou seja, o direito à saúde, embora seja obrigação do Estado, não assegura de forma irrestrita o fornecimento do medicamento pretendido pelo paciente, sem caráter de urgência, preterindo outros que, melhores posicionados na lista de espera organizada pelo órgão de saúde, aguardam o mesmo procedimento, sob pena de ruptura do princípio da isonomia.

Em auxílio ao tema em discussão, oportuna a invocação do Enunciado 16 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, realizado em 15/05/2014, em São Paulo/SP:

> *[...] "nas demandas que visam ao acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o autor deve apresentar prova da evidência científica e também a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS".*

Assim, demonstrado que a requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, diante da exegese do art. 373, inc. I, do CPC, bem como amparado pelos elementos de cognição aportados aos autos pelos requeridos e pelo parecer técnico do NAT, outra solução não resta senão a improcedência da demanda em relação aos fármacos **Colágeno (Motilex) e Etodolaco (Flancox 600mg)**.

Já em relação ao medicamento Arpadol (Harpagophytum procumbens), consigno que nada há o que contrapor quanto a concessão do medicamento, eis que a requerente demonstrou por meio dos documentos que acompanha a inicial, que realmente necessita do medicamento elencado, uma vez que se encontra diagnosticada com lombociatalgia crônica de forte intensidade (CID - M.51.1) e, além disso, o parecer do NAT (fls. 32-41) foi favorável a concessão do fármaco o que reforça o convencimento de que o tratamento médico postulado realmente é necessário. Vejamos (fl. 40):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 18/09/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800972-90.2022.8.12.0054 e código ocSyjYx9.

Em razão do exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é favorável ao município fornecer *Harpagophytum procumbens*, e desfavorável ao pedido de Colágeno, Etodolaco.

Com relação à **multa cominatória** (*astreintes*), embora respeitando entendimentos em sentido contrário, não vejo necessidade na sua aplicação em face da Fazenda Pública como instrumento para compelir ao cumprimento da obrigação, haja vista a possibilidade de bloqueio da verba pública em caso de recalcitrância quanto ao cumprimento da determinação judicial, medida mais efetiva e célere, que não onera duplamente o erário público, como a astreinte.

III - Dispositivo

Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, *revogo* a tutela recursal **e julgo parcialmente procedente** o pedido formulado na inicial para, mantendo a tutela antecipada concedida às fls. 42-48, condenar o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Nova Alvorada do Sul/MS, solidariamente, a fornecerem a Acácia Santos Martins o medicamento **Harpagophytum procumbens (Arpadol)**, conforme prescrição médica, no prazo de **15 (quinze) dias**, sob pena de sequestro (bloqueio) de valores do erário para fins de custear o tratamento da parte requerente.

A possibilidade de o magistrado valer-se desse meio executivo, aliás, já está consolidada na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (vide: *REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6/11/2013, julgado na forma do art. 543-C do CPC*). Nessa hipótese, a parte autora deverá informar o descumprimento da decisão nos autos, a fim de que possa ser realizado o bloqueio de valores das contas dos requeridos para aquisição do medicamento suficiente para o período de 6 meses de tratamento.

Deixo de condenar os requeridos nas custas processuais, ante a isenção conferida à Fazenda Pública (art. 24, I, da Lei Estadual n. 3.779/09).

Não obstante, quanto aos honorários advocatícios, **condeno** os requeridos ao pagamento em favor da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, cujo valor arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, considerando a singeleza da causa e o mínimo tempo despendido para o acompanhamento do feito. Em razão da responsabilidade solidária dos entes públicos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 18/09/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800972-90.2022.8.12.0054 e código ocSyjYx9.

requeridos, devem-se responsabilizados na proporção de 50% para cada um, a teor do artigo 87, caput e §2º, do CPC.

No que pertine aos honorários advocatícios devidos pelo Estado do Mato Grosso do Sul, anoto que, no julgamento do Tema 1.002 no STF[1], ao que tudo indica, houve superação do entendimento firmado na Súmula 421, do STJ.

Nos termos do art. 496, § 3º, do CPC, **desnecessário** o reexame necessário, mesmo diante da sucumbência da Fazenda Pública nos autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas necessárias.

Nova Alvorada do Sul, *datado e assinado digitalmente.*

Juliano Luiz Pereira
Juiz de Direito

[1] Tema 1.002 do STF. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5487108&numeroProcesso=1140005&classeProcesso=RE&numeroTema=1002>. Acesso em 05 de setembro de 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO LUIZ PEREIRA, liberado nos autos em 18/09/2023 às 15:01 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800972-90.2022.8.12.0054 e código ocSyjYx9.